

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5029275-06.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SERRA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA para declarar a ilegalidade da decisão de evento 44, DESPADEC1 proferida na ação principal n. 5007852-09.2023.4.02.5006. Consequentemente, ratifico a medida liminar de evento 3, DESPADEC1. Isenção de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 16 de outubro de 2024.

5029275-06.2024.4.02.5001

500003348835 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5029275-06.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado pela União, apontando, como autoridade coatora, o Juízo Substituto da 1ª VF de Serra, e, como ato ilegal, a decisão judicial, proferida na ação de n. 5007852-09.2023.4.02.5006, que determinou a retificação dos cálculos apresentados pela parte credora para *"considerar apenas as rubricas: "DIÁRIA TREINAMENTO OFFSHORE", "FOLGA IND. OFFSHORE PEREGRINO", "FOLGA INDENIZADA OFFSHORE", "FOLGA INDENIZADA", "HORA DE TREINAMENTO EAD" e "DIÁRIA TREINAMENTO"."*

Alegou, em resumo, que o dispositivo da sentença transitada em julgado apenas condenou o réu apenas a repetir o imposto incidente sobre "FOLGAS INDENIZADAS", nada dizendo sobre "rubricas similares". Sustentou que é totalmente descabido deixar para o calculista, seja fazendário, seja judicial, seja o particular do autor, julgar o que entende por rubricas de natureza "FOLGAS INDENIZADAS", afirmando que é exatamente isso que está ocorrendo, pois não há espaço para a discussão do que se entende por "folgas indenizadas" na fase executiva, haja vista que, na maioria das vezes, o contribuinte pleiteia, na sua petição inicial, apenas a devolução do imposto incidente sobre as rubricas "folgas indenizadas" (princípio da adstrição do julgamento ao pedido) ou, ainda, as sentenças transitadas em julgado de forma genérica, em seu dispositivo, determinam a devolução do IR incidente sobre "folgas indenizadas". Ressaltou que a discussão do que se entende por folgas indenizadas somente é cabível na fase cognitiva, devendo o juiz expressamente julgar e constar no dispositivo da sentença o nome das rubricas que entende estarem abrangidas por tal conceito.

Requeru que fosse deferida liminar para suspender o processo até que esta TRES decida o que entende por "folgas indenizadas" constante na coisa julgada que ora se executa e, no mérito, a declaração da ilegalidade da decisão impetrada.

Decisão de evento 3, DESPADEC1 deferindo a liminar pleiteada *"para determinar a suspensão dos efeitos da decisão impetrada, proferida na ação principal de n. 5007852-09.2023.4.02.5006 evento 44, DESPADEC1) até o julgamento deste mandado de segurança"*.

Manifestação da parte autora da ação principal (evento 9, PET1).

Manifestação do MPF (evento 12, PARECER1).

VOTO

Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional no âmbito dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma decisão manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte, causando-lhe dano irreparável ou de muito difícil reparação. Em outros termos, as excepcionais hipóteses que autorizam o manejo do mandado de segurança contra ato judicial devem, necessariamente, configurar pronunciamentos jurisdicionais de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.

Esse é o entendimento do STJ:

*PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DMAE. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA. EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO. 1. **A utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige, além de ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum impugnado seja manifestamente ilegal ou teratológico.** Precedentes: RMS 48.060/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013, RMS 45.740/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29/8/2014, RMS 45.519/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 27/8/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a decisão proferida pelo juízo da execução, que extinguiu o feito executivo ajuizado contra o devedor originário, reconhecendo que o termo de confissão e acordo extrajudicial realizado por terceiro interessado, para pagamento do débito equivaleria a assunção de dívida, prevista no art. 299 do Código Civil/2002, revelando-se ausente manifesta ilegalidade ou teratologia, sendo, incabível a utilização do writ. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 46.144 - MG (2014/0194856-2), DJ 7/6/2016)*

Como se observa, muito embora o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009, e o Enunciado n. 267 da Súmula do STF reputem incabível o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do *mandamus* para se defender de ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

É, portanto, inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada.

Na presente hipótese, o contribuinte ELDER SILVA BORGES ajuizou a ação de n. 5007852-09.2023.4.02.5006 objetivando a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda incidente sobre a rubrica "FOLGAS INDENIZADAS" e a sentença julgou procedente a pretensão inicial (nos termos requeridos na inicial).

Em sede execução, o autor impugnou a conta apresentada pela União, aduzindo que haveria outras rubricas com natureza indenizatória que também deveriam ser objeto de isenção do imposto de renda.

O juízo *a quo* acolheu a pretensão da parte autora e determinou que fosse retificado o cálculo da parte executada para aplicar a isenção tributária sobre as rubricas "DIÁRIA TREINAMENTO OFFSHORE", "FOLGA IND. OFFSHORE PEREGRINO", "FOLGA INDENIZADA OFFSHORE", "FOLGA INDENIZADA", "HORA DE TREINAMENTO EAD" e "DIÁRIA TREINAMENTO", conforme fundamentos a seguir transcritos (evento 44 dos autos originários):

"Da análise dos autos, verifica-se que controvérsia gravita em torno das rubricas a serem consideradas nos cálculos dos valores devidos pela parte ré, bem como da metodologia de cálculo.

Inicialmente, importa registrar que a apuração do indébito deve ser precedida pela recomposição dos rendimentos tributáveis que serviram de base para o cálculo do imposto de renda.

Portanto, devem ser deduzidos os valores de imposto de renda restituídos à parte exequente por ocasião do ajuste atual da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, ainda que o título executivo judicial não tenha sido expresso quanto a esta possibilidade.

Em relação às rubricas, verifica-se que a parte autora incluiu em seu cálculos as verbas recebidas a título de "ADICIONAL DE INTERVALO (HRA) 32,5% OFFSHORE".

Ocorre que referidos valores não possuem natureza de folga indenizada e, portanto, não foram abarcados pela coisa julgada.

Registra-se que, embora o autor tenha recorrido sobre o referido adicional, o pedido da presente ação limitou-se ao que segue:

"3 - Que a presente Ação seja julgada PROCEDENTE, para declaração de não incidência do imposto de renda sobre os valores referentes as Folgas Indenizadas, devendo ser respeitado o regime de competência na contabilização do referido tributo: e a repetição do indébito tributário

relativo à incidência do imposto de renda sobre os valores alusivos as Folgas Indenizadas, devendo a diferença ser restituída devidamente corrigida com base nos critérios de correção que a União corrige seus créditos tributários."

Por conseguinte, a sentença proferida no evento 12, SENT1 também tratou apenas da folgas indenizadas:

"a) DECLARAR a não incidência de imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor a título de folgas indenizadas;

b) CONDENAR a União a restituir o valor indevidamente recolhido a esse título, descontando-se eventuais valores já restituídos administrativamente, o qual deve ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, cujo montante deverá ser apurado em cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal. "

Nesse passo, não apresentado qualquer recurso, ocorreu o trânsito em julgado, não sendo possível, neste momento processual, o acolhimento da pretensão do autor de incluir as referidas parcelas na execução.

De todo modo, verifico que a União também deixou de considerar rubricas referentes às folgas indenizadas.

Portanto, considerando as rubricas indicadas no evento 42, CHEQ2, bem como o disposto acima, deverão ser retificados os cálculos para considerar apenas as rubricas: "DIÁRIA TREINAMENTO OFFSHORE", "FOLGA IND. OFFSHORE PEREGRINO", "FOLGA INDENIZADA OFFSHORE", "FOLGA INDENIZADA", "HORA DE TREINAMENTO EAD" e "DIÁRIA TREINAMENTO".

Assim, intem-se as partes para ciência, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, devendo a União apresentar novos cálculos nos termos acima."

A decisão de evento 3, contudo, apreciando o pedido liminar formalizado nesta ação mandamental, entendeu que haveria violação à coisa julgada, conforme os fundamentos a seguir:

"O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do CPC: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença" (STJ: AgRg no AgRg no AREsp 515.791/RJ .7, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 03/02/2015).

A sentença proferida na ação n. 5007852-09.2023.4.02.5006 julgou procedente a pretensão inicial para "DECLARAR a não incidência de imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor a título de **folgas indenizadas**" e, pela leitura da fundamentação da decisão, nota-se que tratou apenas de tal verba:

"A controvérsia posta em discussão nos autos diz respeito à análise sobre se a verba denominada "folga indenizada" é passível de incidência do imposto sobre a renda, segundo a sistemática prevista no artigo 43, I e II do CTN que, por sua vez, assim dispõe:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre renda e provento de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Portanto, o fato gerador do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, sendo essa decorrente do acréscimo patrimonial, produto do capital ou trabalho, e os proventos são decorrentes de uma atividade que já cessou, o que não se confunde com a indenização ou reparação, que apenas recompõe algo já adquirido.

O art. 3º da Lei 7713/88, que altera a legislação do imposto de renda estabelece que:

Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei. **(Vide Lei 8.023, de 12.4.90)**

§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

No mesmo sentido, dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9580/2018) :

Art. 33. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e as pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza e os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados **(Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, caput, incisos I e II; e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 1º).**

Art. 34. A tributação independe da denominação dos rendimentos, dos títulos ou dos direitos, da localização, da condição jurídica ou da nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou dos proventos, sendo suficiente, para a incidência do imposto sobre a renda, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (**Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1º; e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 4º).**

*Parágrafo único. Sem prejuízo do ajuste anual, se for o caso, os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado como tal aquele da entrega de recursos pela fonte pagadora, inclusive por meio de depósito em instituição financeira em favor do beneficiário (**Lei nº 7.713, de 1988, art. 2º; e Lei nº 8.134, de 1990, art. 2º ao art. 4º**)*

No caso, pretende a parte autora a exclusão do pagamento de indenização referente ao pagamento das folgas não concedidas oportunamente da base de cálculo do imposto de renda. Afirma que recebeu valores relativos a folgas indenizadas, sobre as quais incidiu imposto de renda indevidamente.

Nesse ponto, cabe salientar que o autor juntou aos autos diversos contracheques indicando o recebimento de indenização por folga trabalhada, sobre as quais ocorreu a incidência do imposto de renda (evento 1, CHEQ5).

Assim, forçoso reconhecer que as verbas recebidas pelo autor a título de indenização por folga não gozada ostentam caráter indenizatório, uma vez que objetivam compensar o trabalhador que não usufruiu das folgas a que teria direito, conforme seu regime de trabalho.

Referida indenização não se confunde com renda nem com produto do trabalho ou proventos de qualquer natureza. A indenização paga pela empresa por folgas trabalhadas não tem por objetivo remunerar hora extra, e sim indenizar a categoria pelos dias de descanso não gozados, pelo que não deve incidir o imposto de renda na fonte sobre esse pagamento. Ademais, a natureza indenizatória do pagamento não se transforma em salarial, diante da conversão em pecúnia desse direito. Em consequência, não incide imposto de renda sobre tais verbas, pois não constituem acréscimos patrimoniais, não se submetendo ao conceito de renda, previsto nos artigos 153, III, da CF e 43 do CTN.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - FOLGAS NÃO-GOZADAS - DIMINUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SISTEMA DE REVEZAMENTO - COMANDO DA CF/88 - ADAPTAÇÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO APENAS EM AGOSTO DE 1990 - ACORDO COLETIVO - PETROBRÁS. INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS - CARÁTER INDENIZATÓRIO - HIPÓTESE DISTINTA DO PAGAMENTO DE HORA-EXTRA A DESTEMPO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - POSSIBILIDADE - RESSALVA DO ENTENDIMENTO DESTE MAGISTRADO NO SENTIDO DE SUA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 83/STJ. As verbas em debate percebidas pelos recorrentes decorrem de indenização por folgas não-gozadas, prevista na Lei n. 5.811/72 e devidas em virtude de alteração promovida nos regimes de turno ininterrupto de revezamento, com o advento da CF/88, que modificou seu regime de trabalho. O sistema de revezamento em que laboravam os recorrentes, conhecido por 1 x 1 (um dia de trabalho por um dia de folga), previsto no art. 2º e seguintes da Lei n. 5.811/72, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, em virtude de uma extensão dos efeitos do inciso XIV do artigo 7º para os empregados que trabalhavam em regime de sobreaviso, passou a ser 1 x 1,5 (um dia de trabalho por um dia e meio de folga). A Petrobrás apenas conseguiu adaptar os contratos de trabalho e implantar turmas de serviço de acordo com o novo regime de trabalho dois anos após a promulgação da CF/88. Por meio de Acordo Coletivo assinado em agosto de 1990, comprometeu-se a indenizar os períodos de folga não-gozados por seus empregados, seguindo as disposições do art. 9º da Lei n. 5.811/72, cuja base de cálculo seria o valor da hora-extra do turno respectivo, bem como indenizar a supressão do adicional de sobreaviso habitualmente pago àqueles. O montante foi acertado em parcelas mensais, pagas de 1995 a 1996, tendo essas verbas sofrido a incidência do imposto de renda na fonte. Com efeito, o dano sofrido pelos empregados da Petrobrás que ensejou a intitulada "Indenização de Horas Trabalhadas" está consubstanciado justamente nos dias de folga acrescidos pela Constituição - mas não-gozados, **percepção que descaracteriza e afasta o tratamento dado ao caso dos autos até o momento como mera hipótese de pagamento de hora-extra a destempo. A impossibilidade do empregado de usufruir desse benefício gera a indenização, porque, negado o direito que deveria ser desfrutado in natura, surge o substitutivo da indenização em pecúnia. A natureza indenizatória desse pagamento não se modifica para salarial, diante da conversão em pecúnia desse direito. O dinheiro pago em substituição a essa "recompensa" não se traduz em riqueza nova, nem tampouco em acréscimo patrimonial, mas apenas recompõe o patrimônio do empregado que sofreu prejuízo por não exercer o direito à folga. Em consequência, não incide o imposto de renda sobre essa indenização.** Recurso especial improvido. (STJ- Órgão Julgador: Segunda Turma. REsp 650080 - Relator: Ministro Humberto Martins, DJ 28/08/2006)

Assim, procede o pleito autoral. Os valores restituídos deverão ser corrigidos somente pela taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, desde o recolhimento indevido.

Por fim, cabe registrar que a análise de quais rubricas são efetivamente referentes ao pagamento de folga indenizada será realizada no momento da execução da sentença."

Ora, com o trânsito em julgado da sentença, as partes ficam adstritas aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Não se trata de erro material.

Ressalta-se que a imutabilidade da coisa julgada material é protegida pelo inciso XXXVI do art. 5º da CF, logo, uma vez proferida a decisão de mérito, transitada em julgado, perfeita se torna a coisa julgada material, gozando o comando sentencial de plena eficácia. Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, que se afigura como lei entre as partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, vedando o reexame da questão porque já definitivamente analisada e julgada.

A decisão impetrada, ao analisar a natureza jurídica das verbas não apreciadas na sentença, violou a coisa julgada, haja vista que o título executivo judicial expressamente consignou a não incidência imposto de renda sobre a rubrica "folgas indenizadas", cabendo-se registrar que não se pode interpretar título judicial, mas apenas cumprir o respectivo comando.

Há de se admitir, portanto, a natureza teratológica da decisão impetrada."

Como se observa, a decisão liminar bem analisou as alegações da parte impetrante e os documentos dos autos principais (5007852-09.2023.4.02.5006), chegando à conclusão de que a decisão impetrada, ao analisar a natureza jurídica das verbas não apreciadas na sentença, violou a coisa julgada, considerando que o título executivo judicial expressamente consignou a não incidência imposto de renda apenas sobre a rubrica "folgas indenizadas".

Dessa forma, mostra-se desnecessário reiterar os fundamentos da decisão supracitada, os quais serão tomados, como razões de decidir, para determinar a execução da sentença proferida na ação n. 5007852-09.2023.4.02.5006, conforme o cálculo apresentado pela parte devedora, no caso, a União.

Da parte dispositiva

VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA para declarar a ilegalidade da decisão de evento 44, DESPADEC1 proferida na ação principal n. 5007852-09.2023.4.02.5006. Consequentemente, ratifico a medida liminar de evento 3, DESPADEC1. Isenção de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009).

5029275-06.2024.4.02.5001

500003300432 .V11